DOI:10.13708/j.cnki.cn11-2640.2010.09.004

建设用地挂钩指标交易的困境与规划建设用地流转

——以重庆"地票"交易为例

吴义茂[1,2]

(1. 西南财经大学法学院，四川 成都，611130；2. 中共佛山市委党校法学部，广东 佛山，528300)

摘要：研究目的：研究建设用地挂钩指标交易面临的问题，提出解决思路。研究方法：理论研究法，实证分析法。研究结果：建设用地挂钩指标交易是解决经济建设与耕地保护矛盾的一个创新，但目前面临指标的"落地困境"与"供给困境"。研究结论：建议在允许集体所有的规划建设用地流转的基础上，把规划建设用地流转与指标交易结合起来统筹考虑。

关键词：土地法学；规划建设用地流转；指标交易

中图分类号：D922.3 **文献标识码**：A **文章编号**：1001-8158(2010)09-0024-05

Difficulties on Construction Land Linked-quota Transaction and the Transfer of Planned Construction Land: Taking Chongqing "Land Ticket" Transfer as an Example

WU Yi-mao[1,2]

(1. Law School, Southwest University of Finance and Economics, Chengdu 611130, China;
2. Law Department, Foshan Municipal Party School, Foshan 528300, China)

Abstract: The purpose of this paper is to explore the existing problems of the construction land linked-quota transaction so as to bring forward some ideas for solution. Methods employed include theoretical study and empirical analysis. The results indicate: (1) the method of construction land linked-quota transaction is an innovation with great significances for solving the contradiction between economic construction and farmland preservation; (2) currently the spot realization and institutional supply of the quotas are in difficulty. It is concluded and advised that the transfer of planned construction land and quota transaction should be considered jointly based on the permission of the transfer of collective planned construction land.

Key words: land law; transfer of planned construction land; quota transaction

1 指标交易及其意义

指标交易是与实物交易相对的概念。指标交易的对象为"指标"，本研究中即指建设用地挂钩指标。所谓建设

收稿日期：2010-05-20
修稿日期：2010-06-16
基金项目：司法部 2007 年度国家法治与法学理论研究课题"农民土地权益法律保障制度研究——以城乡统筹综合配套改革为中心"(07SFB2042)；国家社科基金 2009 年度重点项目"土地承包经营权流转制度'瓶颈'与制度创新"(09AFX002)。
作者简介：吴义茂(1973-)，男，江西新建人，博士研究生，副教授。主要研究方向为经济法学。E-mail：sdxwym@sohu.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

用地挂钩指标指的是农村宅基地及其附属设施用地、乡镇企业用地、农村公共设施和公益事业建设用地等农村集体建设用地复垦为耕地后，可用于建设用地的指标。指标产生的制度根源在于中国对新增建设用地实行年度计划管理制度。这一制度的目的在于防止耕地“农转非”的失控，保障国家粮食安全。按照规定，建设用地指标的获取是土地“农转非”的前提条件，土地的“农转非”不得突破国家下达的计划指标。由于国家每年下达的计划指标难以满足地方经济建设的需要，通过复垦产生的指标便成为补充建设用地的重要来源。在工业化、城市化大力推进的过程中，如何协调经济建设与耕地保护的关系是一个亟待解决的问题，指标交易制度是一个积极探索。2008 年 12 月 1 日实施的《重庆农村土地交易所管理暂行办法》在总则中把指标交易和实物交易并列规定为农村土地交易所的两大交易品种，并以专章的形式规定了指标交易。2008 年 12 月 4 日，新成立的重庆农村土地交易所以“地票”的形式现场进行了首次拍卖。指标交易是对国土资源部《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》（以下简称为“办法”）提出的“增减挂钩”的贯彻与创新，其重大创新意义体现在以下几个方面。

第一，国土资源部《办法》实行的是“先占后补”，往往出现“占有余”而“补不足”。指标交易制度是“先造地后用地”，先把农村建设用地转化成耕地之后，才在城市新增建设用地，对耕地的保护力度更大、效果更好。一方面，农村闲置土地资源依法有序退出，解决农村建设用地浪费问题；另一方面，城市建设用地有比例有节奏地增加，解决城市建设用地紧张的矛盾，但城乡建设用地总量不增加、耕地总量不减少。

第二，国土资源部《办法》实行挂钩指标“总量控制、封闭运行”的原则，农村建设用地与城市建设用地指标是小范围的置换，不能突破项目区的范围。而重庆通过农村土地交易所，真正实现了农村建设用地大范围、远距离的置换。边远区县的建设用地指标也可以卖到主城，用于主城的建设用地，可以卖出更高的价格，从而提升偏远地区的土地价值。据重庆市常务副市长黄奇帆称，地票交易的收入，将全部返到农村，这为大城市反哺大农村，找到了一个新的资金渠道[1]。

2 指标交易的困境

2.1 指标的“落地困境”

地票不是“土地”的“票据化”，也不是“土地权益”的“票据化”，更不是农村土地“承包经营权”的“票据化”，而是“指标”的“票据化”[2]。通过地票交易受让建设用地指标只是获得了增加等量建设用地的资格，具备了将等量的农用地“农转非”的前提条件，并不意味着就现实地获得了建设用地使用权。指标要转化为现实的建设用地使用权，还存在一个指标的“落地”问题（即落实到具体地块）。在重庆的地票模式中，拿到地票的权利人可以选择符合城乡规划和土地规划的相应耕地，拟做自身建设项目，然后申请政府征收土地，政府将开发者所选耕地征转为城镇建设用地后再出让给地票权利人[3]。由此可见，重庆地票交易中的指标的“落地”是通过政府行使土地征收权的方式来实现的。中国包括《宪法》、《土地管理法》、《物权法》在内的法律都将国家对农民集体土地的征收限定在公共利益目的范围，在公共利益目的之外国家不得征收农民集体所有的土地，否则就是对征收权力的滥用①。十七届三中全会明确指出：改革征地制度，严格界定公益性用地和经营性用地，逐步缩小征地范围。因此，经营性项目的建设用地不能通过政府征收去解决是依法治国的要求，是执政党现阶段的政策抉择。目前存在的问题是，重庆已经下达相关文件，规定主城区的经营性用地只能使用地票[4]。这就出现一个悖论：一方面，经营性建设用地只能使用地票；另一方面，经营性项目又不具备“公共利益”的要件因而不属于土地征收范围。地票交易获得的指标势必面临一个无法落地的困境，不解决这一困境，将直接影响指标交易的前景，甚至可能导致经营性项目用地来源的枯竭。据悉，重庆土地交易所成立至今开场交易 4 次，卖出 14 张地票，虽有 7 张地票落地地块已经基本确定，

① 2004 年修改后的《宪法》第 10 条明确规定“国家为了公共利益的需要，可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿”。此后，《土地管理法》也作了相应的修改，即将原第 2 条第 3 款修改为：“国家为了公共利益的需要，可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿”。将原有关条文中的“征用”改为“征收”。《物权法》第 42 条第 1 款规定：“为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

但事实上还没有一张地票落地[4]。因此,指标的“落地困境”不仅是基于法律理论的逻辑演绎结果,而且是指标交易必须解决的现实问题。指标交易要可持续推进,必须要解决这一法律困境。

2.2 指标的“供给困境”

地票交易中的指标来源于农村建设用地复垦。土地复垦有利于增加耕地数量,维护国家粮食安全,符合社会公共利益。但是任何人不能强迫农民为了成就“社会公共利益”而牺牲“个人的私益”,复垦对农民而言是一种可选择的权利,而不是必须履行的法律义务。复垦的收益对农民的选择起着决定性的作用,若复垦收益太低则不能形成对农民有效激励。复垦收益为地票价格扣除复垦成本后的差额。从重庆农村土地交易所的两宗地票交易情况看,1100 亩共拍得 8980 万元,平均每亩约 8 万元。考虑交易过程中的一些中间费用,按照现有拍卖价格加权平均,预计返还到农村的收益大概能达到拍卖价格的 90%,约 7 万元 / 亩[5]。据了解,目前重庆每亩土地的复垦成本在 4—5 万元。因此,农民复垦土地的每亩收益大约为 2—3 万元。这种复垦收益与城市郊区建设用地的收益相比,显然有很大差距,基于经济考虑,城市郊区的农民是不愿意将建设用地复垦为耕地的[6] 对于经济欠发达的远离城镇的农民,转让地票的收益,对提高其生活质量也难以产生实质性改变[2]。因此,目前的复垦收益难以对农民选择复垦产生有效激励,没有农民基于经济利益考虑而产生的复垦积极性,仅靠行政力推动,难以产生可持续的指标的供给,指标的“供给困境”在所难免。

笔者认为,指标交易中的两个困境不是独立的,而是有密切相关性。指标的“落地困境”给指标的竞购者带来了有关受让指标的价值隐忧,直接影响指标交易市场的活跃性。在交易市场不活跃的情形下,指标的交易价格很难达到一个合理水平,而指标的价格直接关涉农民的复垦收益。没有合理的复垦收益,交易指标的产生将成为无源之水、无本之木,指标“供给困境”的产生也就有了某种必然。

3 “禁止规划建设用地流转”理由之证伪

集体建设用地包括存量建设用地和规划建设用地。存量建设用地是现实可用的,规划建设用地指的是按照土地利用规划、城镇建设规划已经纳入建设用地规划,但尚未按照土地利用年度计划进行审批的“未来的可用”而非“现实可用”的建设用地。存量建设用地毫无疑问可以作为流转的客体,而规划建设用地能否作为交易的对象殊值研究。大多数学者认为,规划建设用地不能作为流转的客体①。如岳晓武等认为,申请流转的土地,必须是依法办理了农用地转用手续,取得了集体建设用地使用权的土地,这是流转的必要前提[7]。李延荣也认为,规划建设用地在未经“农转非”审批的情形下不得作为交易的客体,并提出如下理由:“根据《土地管理法》第 44 条的规定,在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内,为实施该规划而将农用地转为建设用地的,应按土地利用年度计划分批次由原批准土地利用总体规划的机关批准。在已批准的农用地转用范围内,具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。可见,规划建设用地要成为现实的建设用地还需经有审批权的人民政府按土地利用年度计划分批次批准。若将未经审批的规划建设用地使用权作为流转的客体,实质上是规避建设用地的审批,为扩大建设用地规模创造条件,耕地保护将更加艰难”[8]。笔者认为,上述观点值得商榷。上述观点的主要依据在于《土地管理法》第 44 条的规定,因此正确理解《土地管理法》44 条的规定就成为评判上述观点的关键所在。

3.1 从文义上解读《土地管理法》第 44 条

“法律解释必先由文义解释入手,且所作解释不能超过可能的文义。否则,即超越法律解释之范围,而进入另一阶段之造法活动[9]。从文义上看,《土地管理法》第 44 条未有任何文句对规划建设用地使用权的流转进行规范,既没说允许流转,也未言禁止交易。因此,笔者认为,所谓“《土地管理法》第 44 条禁止规划建设用地流转”的观点“超越了法律解释的范围”。按照“法不禁止皆可为”的私权理念,应允许作为财产权的规划建设用地使用权流转。

① 在笔者有限的资料收集过程中,尚未发现有学者撰文认为规划建设用地属于流转的客体。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.2 从立法目的上看《土地管理法》第44条

“任何人于解释法律时，须想到的基本问题是：为何设此规定？立法目的何在？立法趣旨之探求，是阐释法律疑义之钥匙”[10]。因此，解释法律应以贯彻、实践立法趣旨为基本任务。《土地管理法》第44条的立法目的在于对耕地的“农转非”进行指标控制以保护耕地、防止耕地流失。从法理上说，规划建设用地使用权流转虽然从字面上不违背《土地管理法》第44条，但如果适用结果违反了《土地管理法》第44条所设定的“耕地保护”的目的，也难谓具有合法性。那么，规划建设用地使用权的流转会直接导致耕地保护的目的落空吗？笔者认为不会。理由在于：第一，规划建设用地使用权的流转与农用地的现实“农转非”是两个完全不同的概念。规划建设用地的流转仅仅意味着产权主体的变更，农用地的现实“非农化”才涉及土地用途的变更，关涉耕地保护问题。土地的产权主体发生变更，并不意味土地用途就一定发生变更。若规划建设用地流转后受让人暂时不将其“农转非”，就不存在耕地的流失问题，当然也不存在与《土地管理法》立法目的相违背的问题。第二，依据《土地管理法》第44条的规定，为达到耕地保护的目的，对规划建设用地的“农转非”需要根据“土地利用年度计划”进行审批。《土地管理法实施条例》第19条进一步规定：“建设占用土地，涉及农用地转为建设用地的，应当符合土地利用总体规划和土地利用年度计划中确定的农用地转用指标；城市和村庄、集镇建设占用土地，涉及农用地转用的，还应当符合城市规划和村庄、集镇规划。不符合规定的不得批准农用地转为建设用地。”因此，规划建设用地转为现实建设用地需要进行审批，但审批不是政府任意的行为，其依据和标准在于“农地转用指标”。规划建设用地使用权人有了“农地转用指标”，政府就必须依法履行其审批的职责。此时规划建设用地“农转非”，就不存在与《土地管理法》第44条的规定有抵触之处，也不存在任何非法占用耕地以致危及耕地保护的问题。在指标交易作为制度创新在各地隆重推出的语境下，通过市场化的途径获取指标并非是很难实现的问题。

诚然，由于非农用地相对农业产值具有高回报的特点，村民有极大的热情将耕地转为非农用地，规划建设用地的流转存在引发耕地流失的风险。但只要把规划建设用地的流转与规划建设用地的现实“农转非”严格区分开来，通过“土地利用年度计划”（也即指标）严格控制流转后的规划建设用地的“农转非”，耕地的流失就处于一个可控的状态。耕地保护的核心在于控制“农转非”而非控制“流转”。因此，“禁止规划建设用地使用权流转”的观点难以成立，规划建设用地流转不具有任何违法性。

4 指标交易困境的解决

4.1 指标“落地困境”的解决

经营性项目不具备政府征收的“公共利益”条件，通过地票交易获得指标的权利人的经营性建设项目用地不能通过申请政府征收来解决，因而面临指标的“落地困境”。这一困境的核心在于“缺地块”。按照规定，要把规划建设用地转变为现实建设用地，还需要按照土地利用年度计划进行审批，年度计划审批的实质就在于确保耕地的“农转非”不突破年度计划指标。因此，规划建设用地权利人转用的困境在于“缺指标”。所以，促成“缺指标”的规划建设用地的权利人与“缺地块”的建设用地指标的权利人的合作就能产生“双赢”。一方面，可以实现建设用地指标的顺利落地；另一方面可以实现规划建设用地的现实“非农化”。因此，笔者在此尝试提出解决指标交易中指标的“落地困境”的思路：正确解读《土地管理法》第44条的规定，破除“禁止规划建设用地使用权流转”的思维定势，在允许规划建设用地流转的基础上，拟投资经营性建设项目的建设用地指标的权利人可以直接从集体所有的规划建设用地使用权人手中受让“缺指标”的规划建设用地使用权，借以实现规划建设用地使用权人与指标的所有人“合二为一”，为此，“缺指标”与“缺地块”的缺陷均得以克服，规划建设用地得以变为现实建设用地，从而也就最终实现了指标的落地。

这一解决思路的特点在于：第一，拟用于经营性建设项目的挂钩指标的落地不是通过政府行使征收权来解决，而是由指标的权利人与规划建设用地使用权人通过平等协商来解决。这样有利于实化农民土地资产权利，提高农民土地流转收益，也有利于减轻土地征收给政府带来的压力和社会和谐；第二，在规划建设用地获得“农转

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

非”指标的情况下,将其转用于现实建设用地不会导致耕地流失的失控。因为耕地保护的核心在于控制“农转非”的指标。控制了指标也就使耕地的“农转非”处于可控的范围。

4.2 指标“供给困境”的解决

没有给农民合理的复垦收益,就没有对农民复垦的有效激励,指标交易将成为无源之水,无本之木,指标“供给困境”的出现也将在所难免[4]。在复垦成本既定的条件下,要提高农民的复垦收益必须提高指标的交易价格。在指标通过市场化途径配置的条件下,指标交易的价格的形成与指标交易市场的活跃程度密切相关。显然,在不活跃的指标交易市场条件下,难以形成指标的合理价格。在重庆,交易市场不活跃与指标的落地难以及由此带来的指标竞购者的隐忧是密切相关的①。据悉,重庆土地交易所设立的土地交易市场并不活跃,自 2008 年 12 月 4 日成立至今开场交易 4 次,卖出 14 张地票[4]。截止 2009 年 8 月底,重庆已经交易地票 4600 亩。其中 12 份共 2700 亩地票被土地储备机构所得,5 宗 1100 亩地票被民营企业所得。显然,地票对开发者吸引力不大[4]。

如上文所述,“禁止规划建设用地的流转”是对《土地管理法》第 44 条的误读,规划建设用地流转不具有任何违法性。规划建设用地使用权流转所指向的目标当然是将其现实的“非农化”,如果不能将其变为现实的建设用地,规划建设用地使用权的流转也就失去了现实意义。但是,规划建设用地的现实“非农化”的前提条件是土地“农转非”指标的获取。因此,允许规划建设用地流转的结果将导致对土地“农转非”指标的更大需求。在指标供给既定的条件下,指标需求的增加必然带来指标交易价格的提升。此外,解决了指标落地难的困境从某种意义上也消除了指标权利人的隐忧和顾虑,有利于提高指标竞购者的积极性,从而有利于激活指标交易市场。在活跃的市场条件下,市场的价格发现功能会把指标的价格调节到一个合理的水平,从而提高农民的复垦收益和复垦积极性。指标在合理的复垦收益激励下将会源源不断得到供给,指标的“供给困境”也将不复存在。因此,统筹指标交易市场与规划建设用地流转市场,是解决地票交易面临困境的有效途径。

参考文献(References):

[1] 重庆农村土地交易所挂牌成立[EB/OL]. http://www.house.online.cq.cn, 2010 - 4 - 26.
[2] 郭振杰. “地票”的创新价值及制度突破[J]. 重庆社会科学,2009,(4):71 - 75.
[3] 王守军,杨明洪. 农村宅基地使用权地票交易分析[J]. 财经科学,2009,(4):95 - 101.
[4] 沈萍. 地票交易制度的创新、困境及出路[EB/OL]. http://prosp.fyfz.cn,2010 - 4 - 26.
[5] 陶卫华,李静. 重庆“地票”带来了什么[EB/OL]. http://www.chinareviewnews.com,2010 - 4 - 26.
[6] 黄忠. 浅议“地票”的风险[J]. 中国土地,2009,(9):36- 39.
[7] 岳晓武,雷爱先. 农民集体所有建设用地使用权流转若干问题[J]. 中国土地,2005,(12):9 - 11.
[8] 李延荣. 集体建设用地流转要分清主客体[J]. 中国土地,2006,(2):14 - 15.
[9] 梁慧星. 民法解释学[M].中国政法大学出版社,1995:214.
[10] 王泽鉴. 民法实例研习·基础理论[M]. 台北:三民书局,1982:142.

① 重庆地票交易竞购者的顾虑除公共利益的原因限制政府征地外,还在于地票交易后的落地在很大程度上仍然系于政府手中,地票的竞购者并无任何特权,当竞购者在指标落地时竞标失败时,则地票还得按原价转让给竞标成功者,利息损失作为投资风险由交易竞购者支付。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net